

第 18 問

Xは10月24日深夜2時、札幌市北区の公園で、近くにある病院勤務の看護師A子（24歳）が帰宅途中であったのを目撃し、密かに接近し、背後から羽交い絞めにした後、アーミーナイフをちらつかせ、「おとなしくしないと、痛い目にあうぞ」と脅し、その場でA子を強いて性交した。性交後、A子はショックで失神した。その際、XはA子が持つ鞆の中から飛び出た有名ブランド製の財布を見つけ、A子が気を失った状態を奇貨として、現金12,000円の入ったその財布を持ち去った。

自宅に帰ったXは仮眠したが、朝10時に外出する前に、何ら事情を明かすことなく、母親Yに財布を保管するように頼んだ。Yはこれを自分の机の引き出しに保管したが、夕方になってXの言動を不審に思い、中を見ると見知らぬA子名義のクレジットカードや免許証があったので、明らかに他人のものであることがわかった。そこでYはかつて法律事務所の事務員として働いた経験のあるZに相談したところ、ZはYに対し、「預かったものを保管することはいわゆる正当な業務であって、罰せられないんだ。安心していいよ。」と説明したので、Yはこれを聞いて安心し、そのまま保管し続けた。

以上の事案における、X及びYの罪責を検討せよ。なお、特別法違反については検討する必要がない。

（北海道大学法科大学院 平成21年度 改題）

第1 Xの罪責について

1 Aを強いて性交した行為について

強制性交等致傷罪（181Ⅱ）が成立することに問題はない。

2 財布を持ち去った行為について

強盗罪（236Ⅰ）の成否を検討すべきであるが、財布を奪取する意思は、Aの失神後に生じているから、強盗の故意の有無が問題となる（**論点** 事後的奪取意思  司H28,R2,旧H2-2,H6-2）。

 205 頁  88 頁

この点については、新たな暴行・脅迫があり、これを強盗罪の実行行為としての暴行・脅迫と評価することができる場合には、強盗罪（本問では、強盗・強制性交等罪）が成立するという立場が一般的である（大阪高判平元.3.3、東京高判平20.3.19【百選Ⅱ42】）。

本問では、新たな暴行（脅迫）も認められないから強盗罪は成立せず、窃盗罪（235）が成立するととどまる。

第2 Yの罪責について

1 Yは、Xが窃取した財布を保管しており、この行為について盗品等保管罪（256Ⅱ）の成否が問題となる。

夕方までの時点では盗品であることの認識がないが、それ以降はその旨の認識があるから、知情後の保管罪の成否が問題となる（**論点** 盗品等保管罪（256Ⅱ）における知情の時期  司R3,予H26,旧H4-2,H14-2）。判例（最決昭50.6.12【百選Ⅱ76】）は、「赃物であることを知らずに物品の保管を開始した後、赃物であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、赃物の寄蔵にあたるものというべき」であるとして、この点肯定するから、Yの行為は盗品等保管罪の構成要件に該当する。

 258 頁  130 頁

2 もっとも、Yは預かったものを保管することは正当な業務であると考えているから、故意（責任）の有無が問題となる（**論点** 違法性の錯誤（法律の錯誤））。

 93 頁  36 頁

本問事案の下では、どのような立場に立ったとしても、基本的に故意（責任）を阻却することはないだろう。

3 また、YはXの母親であるから、257条1項の適用が考えられる。本件では本犯者と盗品犯人とは親族であるが、被害者は親族でないため、257条1項が適用されるか争いがある（**論点** 257条1項における親族関係は犯人と誰との間に必要か 旧H10-2）。

 261 頁  132 頁

判例（最決昭38.11.8）は、「刑法257条1項は、本犯と赃物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、赃物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものである」としているから、この立場によれば、本問でも257条1項の適用が肯定される。

答案構成

第1 Xの罪責について

1 Aを強いて性交した行為について

強制性交致傷罪（181Ⅱ）成立

2 財布を持ち去った行為について

強盗・強制性交等罪（241Ⅰ）の成否

↓

事後的奪取意思

↓

財物奪取の意図が生じた後に新たな暴行・脅迫が必要

↓

あてはめ

↓

強盗・強制性交等罪不成立

↓

窃盗罪（235）成立

3 罪数

強制性交致傷罪と窃盗罪は併合罪（45前段）

第2 Yの罪責について

1 盗品保管罪の成否（256Ⅲ）

↓

知情後保管の可罰性

↓

可罰説（保管途中から盗品等であることを認識した場合において、それ以降も本犯者のために保管を継続すれば同罪が成立する）

↓

2 違法性の錯誤（38Ⅲ）

↓

制限故意説

↓

あてはめ

↓

3 257条1項の適否

↓

257条1項所定の親族関係は、本犯者と盗品等関与罪の犯人との間に必要

↓

あてはめ

↓

4 Yには盗品保管罪が成立するが、刑が自動的に免除される

第1 Xの罪責について

1 Aを強いて性交した行為について

Xが、A（24歳）を羽交い絞めにした上、アーミーナイフで脅した行為は、客観的に反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫といえる。そして、Xは、Aを「性交」し、これによって同人を失神させるに至っているため、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交」（177条）し、「よって人を」負「傷させた」ものとして、強制性交致傷罪（181条2項）が成立する。

2 財布を持ち去った行為について

(1) Xは、Aが失神した状態で、Aの財布を持ち去っている。このAの失神は、Xの暴行・脅迫により生じたものであるから、「強制性交等の罪……を犯した者が強盗の罪……をも犯した」ものとして、強盗・強制性交等罪（241条1項）の成立可能性がある。

(2) もっとも、Aに対する暴行・脅迫は性交のために行ったものであり、財物奪取の意図はその後に生じている。強盗は暴行・脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるから、強盗が成立するためには、財物の強取に向けられた暴行・脅迫が必要であり、事後的に財物の奪取意思を生じた場合は、強盗は成立しないのが原則である。

一方で、財物奪取の意図が生じた後に新たに暴行・脅迫があれば、上記関係及びその認識が認められるから、強盗としてよい。

(3) 本問では、Aが失神した後、Xは新たに暴行・脅迫を加えておらず、Xは失神状態を利用して財布を奪取したにすぎない。

1

よって、Xに強盗は成立せず、強盗・強制性交等罪も成立しない。

もっとも、Aの意思に反して財布を持ち去っているため、「他人の財物を窃取」したといえ、窃盗罪（235条）が成立する。

3 罪数

以上より、Xには、強制性交致傷罪及び窃盗罪が成立し、両者は別の法益に向けられたものであるから、併合罪（45条前段）となる。

第2 Yの罪責について

1 Yが、Xが窃取した財布を保管した行為は、「盗品」（256条1項）を「保管」（同条2項）したものであるとして、盗品保管罪の客観的構成要件に該当する。

もっとも、夕方までの時点では、他人の財布であることを確認しておらず、盗品であることの認識がないから、故意（38条1項本文）を欠き、同罪は成立しない。

一方で、Yが夕方以降、他人の財布であることを認識した後は、少なくとも未必的な盗品性の認識があるから、故意に欠けることなく、同罪が成立し得るのではないか。

盗品等を保管すれば、被害者の追求権侵害の状態が継続し、その間保管行為も継続する以上、盗品等保管罪は継続犯であると解すべきである。また、事後従犯的性格は保管後に盗品性を認識した場合でも異ならない。

したがって、保管途中から盗品等であることを認識した場合において、それ以降も本犯者のために保管を継続すれば同罪が成立する。

2

本問でも、Yが上記時点以降もXのためにその保管を継続した行為については、故意に欠けるところがなく、同罪が成立し得る。

2(1) もっとも、Yは、法律事務所の元事務員Zから「預かったものを保管することはいわゆる正当な業務であって、罰せられない」との説明を受け、安心して保管している。このようにYはZの説明により盗品の保管は犯罪にならないと認識しており、違法性の認識が欠如しているが、これが故意の成否にいかなる影響を及ぼすか。38条3項が、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と定めていることから問題となる。

(2) 故意責任の本質は、規範に直面し、反対動機の形成が可能だったにもかかわらずあえて行為に及んだことに対する道義的非難である。そして、規範に無関心な人格態度という点で、違法性の意識がない場合も、違法性の意識がある場合と同様の非難が可能である。そうだとすれば、違法性の意識は不要と解する。

もっとも、違法性の意識の可能性すらない場合は、これを非難できないから故意を阻却し、過失犯の成否が問題になるにすぎないというべきである。

自説からは、38条3項本文は、法律の規定を知らないことは故意の成立を妨げない旨の規定であり、違法性の錯誤に関する規定ではないと解される。

(3) 本問では、確かに、Yは法律事務所の元事務員Zの説明を信用したものである。しかし、弁護士ではなく、法律事務所の元事務員程度で

3

は、法の見解に社会的信用があるわけではないから、違法性の意識の可能性は十分に存したものと認められる。

よって、故意は阻却されず、Yには、盗品保管罪が成立する。

3(1) そうだとしても、Yは、Xの母親であり、Xの「直系血族」に当たるから、「刑」が必要的に「免除」される可能性がある(257条1項)。しかし、本犯者Xと盗品犯人Yとの間には親族関係が存するが、被害者Aとの間には存しないため、257条1項の親族関係はどの範囲に必要か問題となる。

(2) 盗品等関与罪の犯人が親族たる本犯者を保護したり、本犯者の利益に預かったりするために本犯の犯罪に関与することは社会類型的によくみられるところであり、また、そのような関与は期待可能性が乏しいといえる。それゆえ、257条1項は、盗品等関与罪が被害者の追求権を侵害するのみならず、本犯者庇護という事後従犯的側面を有することを併せて考慮し、親族が本犯の場合には、適法行為の期待可能性が減少することを理由に、一身的に処罰を阻却し、刑の免除を認めたものであると考えられる。

そうだとすれば、同項所定の親族関係は、本犯者と盗品等関与罪の犯人との間に必要であると解すべきである。

上記のように、Yは本犯者Xの「直系血族」であるから、257条1項の適用がある。

4 以上より、Yには盗品保管罪が成立するが、刑が必要的に免除される。

以上

4